

행정법 — 문제 & 모범답안 정리

제1문(설문 5) · 제2문(설문 1·2·3) | 총 100점

제 1 문

사실관계

서울특별시 종로구 X아파트 주민 甲은 서울특별시 상수도사업본부가 팔당호와 팔당댐 하류의 한강 본류 하천구간으로부터 공급하는 수돗물을 사용하고 있다. 서울특별시 중부수도사업소장은 2017. 3. 2. X아파트 관리주체에게 물이용부담금 부과 고지서를 발송하였고, X아파트 관리사무소가 수도요금(상·하수도 요금 및 물이용부담금)을 산출하여 甲을 비롯한 각 세대에 관리비 납부고지를 하였다.

甲은 2017. 6. 9. 서울행정법원에 서울특별시 중부수도사업소장을 상대로 물이용부담금을 부과하는 처분의 취소를 구하는 소를 제기하고(서울행정법원 2017구합3800), 그 소송 계속 중 「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」(이하 ‘한강수계법’)상의 물이용부담금이 헌법상 허용한계를 일탈하여 재산권을 침해한다고 주장하면서 한강수계법 제19조 제1항 및 시행령 제23조·제24조, 「한강수계 물이용부담금 부과율 고시」 제2조에 대하여 위헌법률심판제청신청을 하였으나 2018. 9. 20. 기각되자(서울행정법원 2018아5815), 2018. 10. 12. 한강수계법 제19조 제1항·제5항 및 시행령 제23조·제24조, 부과율 고시 제2조에 대하여 「헌법재판소법」 제68조 제2항의 헌법소원심판을 청구하였다.

설문 5 20점

甲의 위 헌법소원심판청구가 인용되어 위헌결정이 내려졌다고 가정한다. 이때 서울특별시 중부수도사업소장이 甲에게 내렸던 물이용부담금 부과처분의 **법적 효력 및 하자의 정도**에 대하여 검토하시오.

(단, 甲이 제기한 물이용부담금 부과처분 취소소송은 아직 확정되지 않은 상황임)

[해설] 설문 5

I. 문제의 소재

물이용부담금 부과처분의 법적 효력 및 하자의 정도와 관련하여 **첫째**, 甲에게 행한 물이용부담금 부과처분이 행정소송법 제19조와 동법 제2조 제1항 제1호에 의하여 취소소송의 대상이 되는 처분인지, **둘째**, 위헌결정의 소급효가 甲에게 미치는지, **셋째**, 부과처분의 하자의 정도가, **넷째**, 부과처분의 법적 효력이 각 문제된다.

II. 취소소송의 대상이 되는 처분인지 여부

1. 판례

취소소송의 대상이 되는 처분이란 행정청의 공법상 행위로서 특정사항에 대하여 법규에 의한 권리의 설정 또는 의무의 부담을 명하거나 기타 법률상 효과를 직접 발생하게 하는 등 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치는 행위를 말한다.

2. 사안의 경우

甲에게 행한 물이용부담금 부과처분은 서울특별시 중부수도사업소장의 한강수계법상 행위로서 한강 본류 하천구간으로부터 공급하는 수돗물을 사용하는 자들에 대하여 물이용부담금 납부의무의 부담을 명하므로, 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치는 행위이어서 취소소송의 대상이 되는 처분이다. 이를 **원인자부담금처분**이라 한다.

III. 위헌결정의 소급효가 甲에게 미치는지 여부

1. 판례

헌법재판소의 위헌결정의 효력은 위헌제청을 한 ‘**당해사건**’, 위헌결정이 있기 전에 이와 동종의 위헌 여부에 관하여 헌법재판소에 위헌여부심판제청을 하였거나 법원에 위헌여부심판제청신청을 한 ‘**동종사건**’과, 따로 위헌제청신청은 아니하였지만 당해 법률 또는 법률 조항이 재판의 전제가 되어 법원에 계속 중인 ‘**병행사건**’뿐만 아니라, 위헌결정 이후 같은 이유로 제소된 ‘**일반사건**’에도 미친다.

2. 사안의 경우

甲은 2017. 6. 9. 물이용부담금 부과처분 취소소송을 제기하고, 그 소송 계속 중 근거법령에 대하여 위헌법률심판제청신청을 하였으나 기각되자 「헌법재판소법」 제68조 제2항의 헌법소원심판을 청구하였고, 그 청구가 인용되어 위헌결정이 내려졌다. 甲이 제기한 취소소송은 위헌제청신청은 기각되었지만 **당해 위헌심사형 헌법소원심판의 당사자**이므로, 위헌결정의 소급효가 甲에게 미친다.

IV. 부과처분의 하자의 정도

1. 판례

하자가 무효가 되려면 그 하자가 **중대한** 법규위반이면서 **명백한** 법규위반이어야 한다(중대명백설).

2. 사안의 경우

일반적으로 법률이 헌법에 위배된다는 사정은 위헌결정이 있기 전에는 객관적으로 명백하다고 할 수 없어, 위헌결정 전에 행정처분의 근거법률이 헌법에 위배된다는 사유는 특별한 사정이 없는 한 취소소송의 전제가 될 수 있을 뿐 당연무효사유는 아니다. 甲에게 행한 부과처분은 위헌결정으로 결과적으로 근거가 없는 처분이 되어 중대한 법규위반이지만, 위헌결정 전(즉 처분시)에는 객관적으로 명백하다고 할 수 없으므로 하자의 정도는 **취소사유**이다.

참고. 헌법재판소는 행정처분의 효력이 쟁송기간 경과 후에도 존속 중인 경우, 특히 그 처분이 위헌법률에 근거하여 내려졌고 그 목적 달성을 위하여 후행 행정처분이 필요한데 후행처분이 아직 이루어지지 않은 예외적 경우에는 당연무효사유로 보아 쟁송기간 경과 후에도 무효확인을 구할 수 있다고 한다.

V. 부과처분의 법적 효력

부과처분의 하자의 정도는 취소사유이므로 일응 유효한 효력인 **공정력**이 발생한다. 공정력이 발생한 처분은 불가변력이 발생하지 않는 한 직권취소로, 불가쟁력이 발생하지 않는 한 쟁송취소로 각 소급무효로 할 수 있다. 甲에게 행한 부과처분은 직권취소되지 않았고, 甲이 제기한 취소소송이 아직 확정되지 않아 쟁송취소되지도 아니하였으므로 그 법적 효력은 **유효**하다.

VI. 설문의 해결

물이용부담금 부과처분의 하자의 정도는 **취소사유**이고, 그 법적 효력은 **유효**하다.

제 2 문

사실관계

B시장은 2021. 1. 4. 국립대학법인 A대학교에 B시가 관리하는 도로를 장기간 무단으로 점유하였다는 이유로 「도로법」 제72조 제1항에 따라 변상금을 부과하였으나, A대학교는 이를 납부하지 않았다. 한편 A대학교는 교내 미술사도서관이 거의 이용되지 않는 상황에서, 학내에 대형 공연장을 설치하여 일반 공중에 대여하는 수익사업으로 재정적 어려움을 해소할 목적으로, 2020. 9. 3. 관할 B시장에게 위 미술사도서관을 공연장으로 용도변경하기 위한 협의를 요청하였다.

(위 용도변경에는 토지의 형질변경이 수반되어 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조 제1항 제2호에 따른 개발행위허가가 필요하며, 「건축법」 제11조·제14조는 건축허가·건축신고에 개발행위허가를 의제한다. 미술사도서관은 「건축법」 제19조 제4항 제6호의 ‘교육 및 복지시설군’, 공연장은 같은 항 제4호의 ‘문화 및 집회시설군’에 해당한다.)

그런데 국립대학교에 공연장이 남설되어 사회적 논란이 야기되자 국회에서 모든 국립대학교의 신규 공연장 설치를 제한하는 「건축법」 개정안이 발의되었다. B시장은 이를 인지하여, 법령상 다른 명시적 제한사유가 없음에도 A대학교의 용도변경 협의 요청을 접수하고도 응답을 차일피일 미루었다. 그러던 중 2021. 6. 7. 위 개정안이 국회에서 가결되어 2021. 9. 6.자로 시행되었는데, 국회 논의에서 ‘개정 전 인허가 신청 건에는 구법을 적용하는 경과규정을 두자’는 주장과 ‘경과규정 없이 즉시 시행하자’는 주장이 대립하였으나 **경과규정을 두지 않는 것으로 정리**되었다.

이후 B시장은 “2021. 6. 7.자 개정 「건축법」에 따르면 국립대학교에서는 공연장을 신규로 설치할 수 없음”(“**처분사유 1**”)을 이유로 2021. 9. 15. 위 협의 요청을 거부하였다. 그리고 변상금 체납 절차를 피하고 납부를 유도하기 위하여 “A대학교가 2021. 1. 4.자로 부과한 변상금을 아직 납부하지 않았음”(“**처분사유 2**”)도 처분사유로 제시하였다.

참조 조문

현행 법령과 차이가 있으며, 참조 조문이 현행 법령에 우선함

「건축법」

제11조(건축허가) ① 건축물을 건축하거나 대수선하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.

제14조(건축신고) ① 허가 대상 건축물이라 하더라도 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 미리 허가권자에게 신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다. (제1호~제5호 생략)

제19조(용도변경) ② 사용승인을 받은 건축물의 용도를 변경하려는 자는 다음 구분에 따라 허가권자의 허가를 받거나 신고를 하여야 한다. — 1. 허가 대상: 상위군으로 변경하는 경우 / 2. 신고 대상: 하위군으로 변경하는 경우. ④ 시설군: (제4호) 문화 및 집회시설군, (제6호) 교육 및 복지시설군. ⑦ 제2항에 따른 용도변경에는 제11조·제14조를 준용한다.

제29조(공용건축물에 대한 특례) ① 국가(국립대학법인 포함)나 지방자치단체는 제11조·제14조·제19조·제20조·제83조에 따른 건축·대수선·용도변경 등을 하려는 경우 미리 소재지 관할 허가권자와 **협의**하여야 한다. ② 제1항에 따라 협의한 경우에는 제11조·제14조·제19조·제20조·제83조에 따른 **허가를 받았거나 신고한 것으로 본다.**

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」

제58조(개발행위허가의 기준) ① 허가권자는 신청 내용이 각 호의 기준(용도지역별 규모 적합, 도시·군관리계획 부합, 계획사업 시행 지장 없음, 주변환경·경관 조화, 기반시설 확보계획 적절)에 맞는 경우에만 개발행위허가 또는 변경허가를 하여야 한다.

「도로법」

제69조(점용료등의 강제징수) ④ 도로관리청은 점용료 및 변상금을 납부기한까지 내지 아니하면 **국세 또는 지방세 체납처분의 예에 따라 징수**할 수 있다.

제72조(변상금의 징수) ① 도로관리청은 도로점용허가 없이 또는 그 내용을 초과하여 도로를 점용한 자에 대하여 그 기간에 대하여 점용료의 100분의 120에 상당하는 금액을 변상금으로 징수할 수 있다.

「공유재산 및 물품 관리법」

제81조(변상금의 징수) ① 지방자치단체의 장은 사용·수익허가나 대부계약 없이 공유재산 등을 사용·수익하거나 점유(무단점유)한 자에 대하여 사용료 또는 대부료의 100분의 120에 해당하는 금액을 변상금으로 징수한다.

설문 1 25점

A대학교가 B시장의 용도변경 협의 거부에 대한 취소소송을 제기하려 할 때, 이러한 협의 거부는 **취소소송의 대상**이 될 수 있는지 검토하시오.

[해설] 설문 1

I. 문제의 소재

미술사도서관의 공연장으로의 용도변경협의거부가 취소소송의 대상이 될 수 있는지와 관련하여 **첫째**, 용도변경협의를 자치사무인지 국가위임사무인지, **둘째**, 그 협의거부가 행정소송법 제19조·제2조 제1항 제1호에 의하여 취소소송의 대상이 되는 거부처분인지 문제된다.

II. 용도변경협의를 자치사무인지 국가위임사무인지 여부

1. 판례

법령상 국가사무가 지방자치단체의 장에게 위임되거나 상위 지자체 사무가 하위 지자체의 장에게 위임된 기관위임사무에 관한 사항은 기관위임사무이다. 지자체의 장이 처리하도록 규정된 사무가 자치사무인지 기관위임사무인지를 판단할 때에는 **법령의 규정 형식과 취지**를 우선 고려하되, 그 밖에도 사무의 성질이 **전국적으로 통일적 처리가 요구되는지** 여부, 그에 관한 **경비부담과 최종적 책임귀속의 주체** 등도 아울러 고려하여야 한다.

2. 사안의 경우

① 건축법 제19조의 규정형식·취지가 제11조 건축허가권자의 전문적·기술적 형질변경허가 판단에 기초한다는 점, ② 사무의 성질이 전국적으로 통일적 처리가 요구되는 것이 아니라 지역적 특성에 맞게 공용건축물의 이용에 관한 협의를 한다는 점, ③ 그에 관련한 각종 변상금 등의 부과·귀속 주체가 당해 지방자치단체라는 점에서, 용도변경협의를 **자치사무**이다.

III. 협의거부가 취소소송의 대상이 되는 거부처분인지 여부

1. 문제의 소재

판례에 의하면 행정청의 거부행위가 취소소송의 대상이 되는 거부처분이 되려면, ㉠ 신청한 행위가 처분이어야 하고, ㉡ 거부행위가 신청인의 법적 상태에 어떤 변동을 초래하여야 하며, ㉢ 국민에게 그 행위발동을 요구할 법규상·조리상 **신청권**이 있어야 한다. 건축법 제29조 제1항·제19조 제2항에 따라 용도변경 협의에 관한 법규상 신청권이 인정된다. 이와 관련하여 신청한 행위인 용도변경협의를 처분인지 문제된다.

2. 신청한 행위인 용도변경협의를 처분인지 여부

(1) 판례

취소소송의 대상이 되는 처분이란 행정청의 공법상 행위로서 특정 사항에 대하여 법규에 의하여 권리의 설정 또는 의무의 부담을 명하거나 기타 법률상 효과를 직접 발생하게 하는 등 국민의 권리·의무에 직접 관계가 있는 행위를 말한다.

(2) 사안의 경우

A대학교의 건축물 용도변경은 건축법 제29조의 국립대학법인이 건축물을 용도변경하려는 경우에 해당하므로 같은 조 제1항에 의하여 관할 허가권자와 협의하여야 하고, 제2항은 협의에 대해 **허가 또는 신고로서의 효력**을 부여하고 있으므로, 용도변경 협의의 실질은 용도변경허가 또는 수리를 요하는 용도변경신고의 수리로 보아야 한다. 따라서 신청한 행위인 용도변경협의를 그 실질이 허가 또는 수리에 해당하므로 **처분**이다.

3. 소결

판례는 신청권이 있는 처분에 대한 거부행위는 신청인의 법적 상태에 변동을 초래한다고 본다. 따라서 협의거부는 취소소송의 대상이 되는 거부처분이다.

IV. 설문의 해결

협의거부는 **취소소송의 대상이 된다.**

설문 2 30점

B시장의 각 거부사유(처분사유 1, 2)가 타당한지 검토하십시오.

(단, 처분사유 1의 경우 「민원 처리에 관한 법률」 위반 여부는 검토하지 말 것)

[해설] 설문 2

I. 문제의 소재

각 거부사유의 타당성과 관련하여 **첫째**, 용도변경협의거부가 기속행위인지 재량행위인지, **둘째**, 처분시법이 적용된 처분사유 1이 타당한지, **셋째**, 처분사유 2가 부당결부금지원칙 위반인지 문제된다. (원문 I 은 ‘제14조’로 표기 — 부당결부금지원칙은 행정기본법 제13조로 정정 권장)

II. 용도변경협의거부가 기속행위인지 재량행위인지 여부

1. 판례

당해 행위의 근거가 된 법규의 체제·형식과 그 문언, 당해 행위가 속하는 행정 분야의 주된 목적과 특성, 당해 행위 자체의 개별적 성질과 유형 등을 모두 고려하여 판단하여야 한다.

2. 사안의 경우

판례에 의하면 건축허가는 원칙적으로 기속행위이지만 예외적으로 토지의 형질변경행위를 수반하는 경우 재량행위에 해당한다. 용도변경협의거부의 근거인 건축법 제29조 제1항의 문언상 재량행위인지는 불분명하나, 용도변경협의를 건축허가의 실질을 지니면서 토지의 형질변경행위를 수반하므로 그 협의거부는 **재량행위**이다.

III. 처분시법이 적용된 처분사유 1이 타당한지 여부

1. 문제의 소재

행정기본법 제14조 제2항의 ‘법령등에 특별한 규정이 있는 경우’는 아니므로, ‘**처분 당시의 법령등을 적용하기 곤란한 특별한 사정**이 있는 경우’인지 문제된다.

2. 처분 당시의 법령등을 적용하기 곤란한 특별한 사정이 있는 경우인지 여부

(1) 판례

행정처분은 원칙적으로 처분시의 법령에 준거하여 행하여져야 하므로, 법령의 개정(조례 개정 포함)으로 허가기준이 변경된 경우 특단의 정함이 없는 한 신청시가 아닌 **처분시의 개정법령**에 의한 새로운 허가기준이 적용되어야 한다. 다만 소관행정청이 허가신청을 수리하고도 이유 없이 그 처리를 늦추어 그 사이에 허가기준이 변경된 경우 등 특단의 사정으로 불허가처분이 위법하게 되는 경우는 별론으로 한다. (대법원 1984. 5. 22. 선고 84누77 판결)

(2) 사안의 경우

B시장은 A대학교의 협의 요청을 접수하고도 국회에 계류 중인 개정안을 인지하고 **의도적으로 협의(통보)를 늦춘 것**이므로, 소관행정청이 허가신청을 수리하고도 이유 없이 처리를 늦추어 그 사이에 허가기준이 변경된 경우에 해당한다. 즉 처분 당시의 법령등을 적용하기 곤란한 특별한 사정이 있는 경우이다.

3. 소결

처분시법이 적용된 처분사유 1은 **타당하지 않다**.

IV. 처분사유 2가 부당결부금지원칙(행정기본법 제13조) 위반인지 여부

1. 판례

부당결부금지원칙이란 행정주체가 행정작용을 함에 있어 상대방에게 **실질적 관련이 없는 의무**를 부과하거나 그 이행을 강제하여서는 아니 된다는 원칙이다. (대법원 2009. 2. 12. 선고 2005다65500 판결) ‘실질적 관련성’은 처분의 원인이 된 사실관계와 처분 사이의 합리적 인과관계로서 **원인적 관련성**과 **목적적 관련성**을 의미한다.

2. 사안의 경우

변상금은 용도변경협의거부로 이어지는 일련의 절차에서 부과한 것이 아니므로 미납 변상금과 협의거부 사이에는 **원인적 관련성이 없고**, 미납 변상금 징수는 도로법 제69조 제4항에 따라 지방세 체납처분 절차를 통해 달성하여야 함에도 공물의 사용방법을 달리하려는 목적의 용도변경협의를 거부함으로써 달성하려 하므로 **목적적 관련성도 없다**. 따라서 처분사유 2는 부당결부금지원칙 위반이다.

V. 설문의 해결

협의거부는 재량행위이다. 처분시법이 적용된 **처분사유 1은 타당하지 않고**, **처분사유 2는 부당결부금지원칙 위반으로 타당하지 않다**.

설문 3 25점

A대학교는 B시장의 변상금 부과처분에 대하여 항고소송을 제기하였는데, 사실심 계속 중 A대학교가 “해당 도로는 도로구역으로 결정·고시된 바 없어 「도로법」 상 도로로 볼 수 없으므로 변상금 부과는 무효”라고 주장하자, B시장은 “무단점유한 도로가 사실상 도로라 하더라도 이는 B시의 행정재산이고 A대학교도 이를 알고 있었으므로 「공유재산 및 물품관리법」에 따른 변상금 부과 대상이 된다”라는 **처분사유를 추가**하였다. 이러한 추가는 허용될 수 있는지 검토하시오.

[해설] 설문 3

I. 문제의 소재

처분사유의 추가가 허용되는지와 관련하여 **첫째**, 처분사유의 추가·변경 제도를 인정할 수 있는지, **둘째**, 추가사유인 공유재산법 제81조 제1항이 당초처분사유인 도로법 제72조 제1항과 **기본적 사실관계가 동일**하다고 인정되는 한도 내에 있는지 문제된다.

II. 처분사유의 추가·변경 제도를 인정할 수 있는지 여부

1. 학설

소송법상 규정이 없는 처분사유의 추가·변경과 관련하여, ㉠ 취소소송의 소송물을 행정처분의 위법성 일반으로 보면서 분쟁의 일회적 해결 차원에서 **긍정**하는 견해, ㉡ 소송물을 처분이유에서 특정된 처분의 위법성 일반으로 보면서 이유제시의무(행정절차법 제23조)·방어권 보장·신뢰보호 차원에서 **부정**하는 견해, ㉢ 일정한 범위 내에서 **제한적으로** 긍정하는 견해가 있다.

2. 판례

당초 처분의 근거로 삼은 사유와 **기본적 사실관계가 동일**하다고 인정되는 한도 내에서는 다른 사유를 추가하거나 변경할 수 있다.

3. 검토

분쟁의 일회적 해결, 상대방의 방어권 보장을 통한 실질적 법치주의 구현, 상대방에 대한 신뢰보호를 근거로 **제한적 긍정설 및 판례**가 타당하다.

4. 소결

당초처분사유인 도로법 제72조 제1항과 기본적 사실관계가 동일하다고 인정되는 한도 내에서 다른 사유를 추가할 수 있다.

III. 추가사유가 기본적 사실관계 동일성이 인정되는 한도 내에 있는지 여부

1. 판례

기본적 사실관계가 동일하다는 것은 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 **구체적 사실**에 착안하여 그 기초인 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일한 것을 말하며, 처분 당시에 적시한 구체적 사실을 변경하지 않는 범위에서 단지 근거법령만을 추가·변경하거나 당초 처분사유를 구체적으로 표시하는 데 불과한 경우에는 새로운 처분사유를 추가·변경하는 것이라고 볼 수 없다. 또한 추가·변경된 사유가 당초 처분시 명기되지 않았을 뿐 처분시에 이미 존재하였고 **당사자가 그 사실을 알고 있었다 하여** 당초 처분사유와 동일성이 있다고 할 수 없다.

2. 사안의 경우

공유재산법 제81조 제1항과 도로법 제72조 제1항은 별개 법령에 규정되어 입법 취지가 다르고, 변상금의 징수목적·산정 기준금액·징수 재량 유무·징수절차 등이 서로 달라, 추가사유는 구체적 사실을 변경하지 않는 범위에서 단지 근거법령만을 추가하는 경우가 아니다. 따라서 추가사유인 공유재산법 제81조 제1항은 당초처분사유인 도로법 제72조 제1항과 기본적 사실관계가 동일하다고 인정되는 한도 내에 있지 않다.

IV. 설문의 해결

도로법 제72조 제1항에 공유재산법 제81조 제1항을 추가하는 것은 **허용될 수 없다**. A대학교가 추가되는 처분사유를 알았더라도 이는 처분사유의 추가·변경을 허용하는 사정이 될 수 없다.